

1500317-36.2021.8.26.0341
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Zander Barbosa Dalcin
Comarca: Maracaí
Foro: Foro de Maracaí
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 10/05/2022
... julgado em 08/10/2013).

"Associação para o tráfico de entorpecentes. Não configuração. Estabilidade e permanência não demonstradas. Falta de prova da colaboração constante entre os agentes. Não se deve confundir o mero concurso eventual de agentes com a associação para o tráfico, que demanda provas veementes de sua estruturação. Dúvida que lhes favorece. Absolvição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Maracaí
Foro de Maracaí
Vara Única
Av. São Paulo, 440, Maracai-SP - cep 19840-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500317-36.2021.8.26.0341 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500317-36.2021.8.26.0341
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273880/2021 - DEL.POL.MARACAI, 20696991 - DEL.POL.MARACAI, 440/21/112 - DEL.POL.MARACAI, 2273880 - DEL.POL.MARACAI
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JONATHAN SOARES DA SILVA e outro
Réu Preso
Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Jonathan Soares da Silva e Kelly Cristina Castilho Fonseca foram denunciados como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e do artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do concurso material de crimes, porque, desde data incerta, mas seguramente até o dia 06 de outubro de 2021, associaram-se para praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, Jonathan Soares da Silva e Kelly Cristina Castilho Fonseca transportavam, sem autorização, e, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, 50 porções de crack, prensadas em forma de tijolos, com peso aproximado de 50,3kg, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 57/60 e laudo de exame químico toxicológico de fls.

172/175, sendo certo que tal substância causa dependência física e psíquica.

Os acusados foram notificados (fls. 240 e 271) e apresentaram defesas preliminares (fls. 197/198).

A denúncia foi recebida em 23/11/2021- fls. 218/219.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogados os acusados (fls. 274/276).

Na fase do artigo 402 do CPP, foi determinada a juntada das FA e certidões de ambos os acusados, certidão de objeto e pé da sentença mencionada pelo acusado Jonathan e laudo pericial dos celulares apreendidos em poder dos acusados - fl. 275.

Os laudos foram encartados às fls. 305/313 e 314/319

Em Memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da Ação Penal nos termos da denúncia - fls. 339/345.

A defesa, em Alegações Finais, asseverou a ausência de provas da procedência da droga. Defendeu que a corré não tinha conhecimento de que o companheiro transportava substância entorpecente dentro do veículo, razão pela qual requereu sua absolvição nos termos do artigo 386, VII do CPP, pela aplicação do Princípio do "in dubio pro reo". Em relação ao réu Jonathan, pleiteou o reconhecimento da confissão (fls. 349/363).

Relatei. Decido.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/5), auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo definitivo de fls. 172/175, bem como pela prova oral, coligida sob o crivo do contraditório. A autoria pelo conjunto probatório.

Kelly Cristina Castilho Fonseca, ré, perante a autoridade policial, disse que: "Que saíram de Colorado hoje por volta das 6 horas da manhã com destino a Campinas ou São José do Rio Preto, que não tem certeza, que para a interrogada ele disse que iriam para Itu, visitar a mãe dele. Quando chegou perto de Nantes, Jonathan parou o carro e mostrou para a interrogada o fundo falso no painel e falou que estava levando aproximadamente 30 Kg de droga. Jonathan disse que seria para ajudar a sua cunhada, pois seu irmão está preso e ela passando dificuldade com três crianças. Que somente ficou sabendo da droga durante a viagem. Nas outras vezes que viajou com o Jonathan ele levava a interrogada, mas a deixava na casa de sua sogra, em Itu e sumia. Quando indagava ele onde estava sempre contava um história. Que Jonathan não aparece com o dinheiro em casa, que ele aparece com dinheiro quando precisam, mas não sabe o que ele faz com o dinheiro. Que possui 04 filhas, de 26, 22, 19 e 16 anos. Só a mais nova mora com a interrogada. Que essa é a sua primeira passagem" - fl. 27

Em juízo, declarou que foi convidada pelo acusado Jonathan para ir visitar sua família no Estado de São Paulo, na cidade de Itu. Não tinha conhecimento que ele iria para Campinas. Iam visitar a mãe dele e um parente que estava com problema de coração. Como trabalha bastante, adiantou o serviço para ficar dois dias em Itu. Durante o trajeto, estranhou o fato de ser deixada pelo denunciado Jonathan, por cerca de 40 (quarenta) minutos, em uma panificadora na cidade de Iepê/SP, sob o pretexto de que iria consertar o carro. Porém, dias antes, ele já tinha levado o carro em Londrina. Não tinha motivo para ser largada no local para ele ir ao mecânico. Na volta, notou uma aparência estranha de Jonathan e seguiram viagem. No caminho, de longe, Jonathan avistou os policiais militares, oportunidade em que disse: "Nós perdemos." A acusada questionou: "Perdemos o que?". Já trabalham muito, não havia necessidade de passar por isso, é a segunda vez que passa por isso, em

razão das mentiras do acusado. Trabalhavam, ganhavam de 10 a 12 mil a cada 60 dias, ele não precisava fazer isso. Quando avistou os policiais, Jonathan abriu o compartimento e mostrou um pacote preto, cheio de droga. Ele fechou a tampa e disse "perdemos". Logo em seguida, foram abordados pelos policiais militares. Não conseguiu entender os fatos. Não sabe se ele foi até Campo Grande porque ele não saía, não tinham tempo. Ele sempre ia pescar próximo a Nantes. Lamentavelmente, ele agiu de má-fé, se pudesse, teria tomado um ônibus e "sumido do local". Não tinha necessidade de fazer isso. Conseguiram viver bem. Respondeu aos policiais militares apenas que sabia que tinha droga porque o corréu tinha acabado de fechar o compartimento. Trabalhavam como granjeiros, ficavam no local 24h/48 horas. Já respondeu processo no Paraná e foi absolvida. Tinha conhecimento da droga porque o corréu abriu o compartimento. Ele não justificou o motivo para transportar a quantidade de droga. Não deu tempo de falar nada.

Jonathan Soares da Silva, réu, durante inquérito policial alegou que: "Não houve agressão no momento da abordagem, nem física nem verbal por parte dos policiais militares. Que não apresenta lesões corporais nesta oportunidade. Que sobre os fatos de hoje declara que buscou a droga em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no domingo (dia 03/10/2021), que foi junto com sua esposa, mas deixou ela na casa de um parente. Que essa seria sua terceira viagem para levar drogas. Que todas tinham como destino final a cidade de Campinas. Quer iria receber a quantia de 25 mil pelo transporte a ser pago no final. Que no Whatsapp a pessoa manda a localização para a entrega, que não tem um lugar definido. Que como trabalhou de funileiro, o próprio interrogado que fez o fundo falso no veículo, que o veículo é de sua propriedade e está financiado. Que sempre inventa alguma coisa pra sua esposa, na data de hoje ela ficou sabendo quando saíram de casa, que contou pra ela no caminho. Que já teve passagem na cidade de Guaraci/Pr por tráfico de drogas. Que não tem filhos, mas 04 enteadas, todas filhas da Kelly" - fl;. 16

Durante a instrução, declarou que tinha um contato de um rapaz da cidade de Iepê/SP de anos atrás. Tempos depois foi pescar em Nantes e resolveu ligar para o rapaz, ocasião em que este lhe ensinou a "fazer o serviço" no painel do carro (para o transporte de drogas). Combinou com ele que a esposa não poderia saber que ele carregaria drogas, então iria deixar o automóvel para que colocasse a droga no compartimento escondido e iria com ela até a padaria. Em Iepê, falou pra ela que precisava arrumar o carro e deixou o seu automóvel no local combinado. Foi tomar um café com a esposa nesse meio tempo. Combinou de colocar 30kg mas ele colocou 50Kg de droga. Na oficina, ele informou que a peça tinha sido colocada e o serviço ficaria em R\$ 30,00. Seguiram viagem, e, na rodovia Raposo Tavares, próximo à Maracaí, foram abordados por duas viaturas. Perguntaram sobre a droga, negou que tinha droga. O policial abriu o compartimento com a faca, era um cofre eletrônico e quando bateu, mostrou como abria, o airbag explodiu e viram o compartimento. Até então, não ia falar a verdade. A droga veio de Campo Grande/MS e foi descarregada em Iepê/SP, pegou em Iepê/SP e ia levar para Assis/SP. Até hoje, não recebeu nada pelo transporte. Refere que novamente mentiu para esposa, igual fez em um outro processo judicial. Ganharia R\$ 25.000,00 para levar a droga de Iepê/SP para Assis/SP, porém no caminho os responsáveis mudaram a rota e exigiram a entrega em Campinas/SP. Foi enganado. Respondeu processo-crime pela prática de tráfico de drogas no Estado do Paraná junto com a esposa e com o cunhado, oportunidade em que Kelly Cristina foi Testemunha.

Luiz Fernando dos Santos, policial militar, testemunha de acusação, em juízo, prestou depoimento semelhante ao depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 13), relatou que estavam em fiscalização pela Rodovia Raposo Tavares, no Município de Maracaí, ocasião em que abordaram um veículo Hyundai/Tucson, placas do Paraná, tendo como condutor Jonathan e como passageira, a corré Kelly Cristina. Durante a abordagem, apresentaram nervosismo e informações contraditórias quanto aos motivos da viagem/origem/destino, razão pela qual decidiram realizar uma busca minuciosa no automóvel. Durante a busca, localizaram um compartimento secreto no

painel do veículo, e, depois de aberto, localizaram grande quantidade de crack, 50 tabletes da droga crack. Questionados, ambos os acusados confessaram que saíram da cidade de Campo Grande/MS com destino à Campinas/SP, e levariam a droga pelo preço de R\$ 25.000,00. Não apontaram quem teriam contratado os corréus e nem quem seria o destinatário da droga. Ainda, localizaram dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Ambos os corréus demonstraram ciência do transporte dos entorpecentes. Jonathan ensinou os policiais militares a abrir o compartimento (fundo falso) por meio de acionamento eletrônico, uma combinação de gestos que abria o compartimento. A corré Kelly falou que ganharia R\$25.000,00 para levar a droga com Jonathan. Tanto Kelly como Jonathan informaram que receberiam a quantia, não mencionou quem pagaria a quantia e nem a forma que receberia. Ela já tinha conhecimento prévio sobre o recebimento da quantia para o transporte da droga, foram inquiridos de forma separada. Não informaram o local preciso em que buscaram a droga em Campo Grande. Jonathan que se propôs a ajudar a equipe, mas tinha um forte odor de crack, que vinha do painel, era impossível não ter conhecimento de que tinha droga no local. Era um odor muito forte e até incômodo.

Luis Gustavo da Silva Schwarz, policial militar, testemunha de acusação, durante a instrução, apresentou depoimento semelhante ao depoimento prestado durante inquérito policial (fl. 11), relatou que, juntamente com outro policial militar, efetuavam fiscalização pela cidade de Maracaí, na Rodovia Raposo Tavares e abordaram o veículo conduzido pelo denunciado Jonathan, placas do Paraná, e, em fiscalização decorrente do combate ao tráfico de drogas, questionaram o casal, que apresentaram respostas divergentes. Diante das respostas, realizaram busca pelo veículo e encontraram um fundo falso com uma substância estranha, que não conseguiram identificar à princípio. Questionada, Kelly Cristina confessou se tratar de drogas. Conseguiram acessar o dispositivo e encontraram 50 tabletes de substância, que aparentava ser crack. Os denunciados alegaram que buscaram as drogas na cidade de Campo Grande/MS e que levariam até a cidade de Campinas/SP. Não declinaram os responsáveis pela contratação do serviço e pelo recebimento da droga, informaram que receberiam R\$ 25.000,00 pelo trabalho, para ser dividido pelos dois. Também apreenderam dois celulares e a quantia aproximada de R\$ 1.700,00. Diante dos fatos, foram conduzidos à delegacia de polícia. Confirmou que Kelly Cristina tinha ciência do transporte, quando questionada, respondeu que tinha entorpecentes no fundo falso, não soube precisar o que seria, mas tinha conhecimento. O fundo falso foi localizado pelos policiais. O casal, à princípio, disse que iria visitar a sogra e depois de um tempo, mencionaram que já tinham ido, outro declarou que nunca tinha ido, e, diante das divergências, realizaram a busca. Localizaram o fundo falso mas não o dispositivo de abertura. A forma de abertura, que era realizada por dispositivo eletrônico, foi apontada, posteriormente, pelos acusados, salvo engano, pelo corréu. Segundo eles, a droga foi apreendida em Campo Grande/MS, posteriormente foram até a cidade que residiam, no estado do Paraná, e, em seguida, vieram para o estado de São Paulo. Ambos os acusados relataram as circunstâncias do tráfico. Quando da localização do dispositivo, a corré informou que tinha droga no fundo falso. O dispositivo encontrava-se no local onde estaria o dispositivo de airbag e era aberto de forma eletrônica. Ela falou que teria uma quantidade aproximada de 30 kg mas não soube precisar a natureza da droga.

No tocante ao tráfico, ante a confissão extrajudicial e judicial do acusado Luiz Fernando dos Santos, a matéria não comporta maiores digressões. Além disso, a confissão veio corroborada pelos depoimentos dos policiais militares.

No tocante à corré, as contradições entre os depoimentos de ambos os réus tanto em juízo como na fase policial, demonstram que a corré aderiu à conduta criminosa de Jonathan, e, que, conforme relato dos policiais militares, a corré confirmou que faziam um serviço de transporte de droga, que buscaram o entorpecente na cidade Campo Grande/MS e levariam até Campinas/SP, pelo preço ajustado de R\$ 25.000,00, e, inclusive, a própria corré informou a presença de drogas no veículo.

Não se descure, no aspecto, que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito o ônus probatório, cabendo, portanto, à defesa, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, na hipótese, predito ônus probandi - pela defesa - não foi satisfeito (CPP, art. 156).

Nunca é demais lembrar que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente, quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Confira-se:

"PROVA - Depoimento de policiais - Valor: Reveste-se de idoneidade a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, mesmo que constituída por depoimentos de policiais, não sendo possível desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da repressão penal". (TACrimSP - Ap. nº 1.370.051/1 - Araraquara - 12ª Câmara - Rel. Barbosa de Almeida - J. 29.3.2004 - v.u.).

Oportuno lembrar, ainda, que "a presunção é sempre a favor da autoridade judiciária ou policial. O que se presume é, realmente, a imparcialidade, a correção, a lealdade, a lisura. Precisamente a exceção é que exige prova. Quem acusa a autoridade de arbitrária, de capaz de coagir para extorquir confissões contra a verdade, de forjar depoimentos, de compelir a assinar o que o réu não disse, está no dever de oferecer provas, pois a acusação é das mais graves, é das mais repugnantes." (Ac. TJ do DF - Ap. crim. 5.371, Rel. Des. José Duarte - Plácido Sá Carvalh.o, CPP, p. 182).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

O tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é misto alternativo, de natureza múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, todas as condutas nele descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal. Em outras palavras, o crime se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de comercialização da droga.

O que demonstra a prática do tráfico ilícito de drogas é o dolo do agente de transferir ou repassar a droga a usuários, nos termos de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos presentes no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Eis o que estabelece o artigo 33 da Lei de Antidrogas:

"Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Destarte, para a configuração do crime em apreço, não se exige qualquer ato de

tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que afasta a exigência de se verificar a "traditio" para consumação do delito (TJSP, Apelação Criminal 1506353-79.2020.8.26.0228, Des. Klaus Marquelli Arroyo, j. 16/11/2020).

Por fim, de rigor o reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, pois, ante os relatos dos policiais militares, os réus transportavam expressiva quantidade de droga desde a cidade de Campo Grande/MS, tendo sido apreendido em Maracaí/SP, restando inviável o acolhimento de suas considerações, em especial, no que se refere ao carregamento da droga apreendida na cidade de Iepê/SP porquanto, evidentemente, buscam, com estas, o afastamento da majorante em apreço.

Quanto ao delito de associação criminosa, o concurso (eventual) de agentes não conduz ao reconhecimento, na espécie, da associação para praticar o tráfico de drogas porquanto sua - efetiva - existência dependeria de comprovação afeta à sua estabilidade e permanência, o que, evidentemente, não restou comprovado. Nesse sentido, o magistério de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi:

"Elemento subjetivo do tipo - É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração" (Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, Saraiva, 2008, p. 128). - Grifei!

Ainda:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 exige a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa". (HC 410.277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017)

"O crime do art. 35 da Lei 11.343/06 exige que a associação entre os agentes ocorra de forma estável ou em caráter permanente, caracterizando a reunião eventual mero concurso de pessoas (...)" (STJ, AgRg no AResp 303.213/SP, Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 08/10/2013).

"Associação para o tráfico de entorpecentes. Não configuração. Estabilidade e permanência não demonstradas. Falta de prova da colaboração constante entre os agentes. Não se deve confundir o mero concurso eventual de agentes com a associação para o tráfico, que demanda provas veementes de sua estruturação. Dúvida que lhes favorece. Absolvição mantida. Apelos ministerial improvido. (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Pindamonhangaba; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11.2.2014; Data de registro: 12.2.2014)".

Passo à dosimetria das penas.

Em relação à Jonathan Soares da Silva

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não possui antecedentes. Não há elementos, nos autos,

que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas foram apreendidas em quantidade elevada, a natureza da droga apreendida, de alto poder destrutivo enseja o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, conforme artigo 65, III, alínea "d" do Código Penal. Em que pese os argumentos do Ministério Público, a condenação certificada às fls. 332/335 não pode ser considerada como reincidência pois não há informação quanto ao trânsito em julgado. Nesse sentido, diminuo a reprimenda na fração de 1/6, perfazendo o total de 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 520 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na derradeira fase da dosimetria, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois as circunstâncias da abordagem indicam a dedicação a atividades criminosas. Presente a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, pois o intuito do réu era transportar os entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nesse sentido, aumento as reprimendas na fração de 1/6, e fixo-a, definitivamente em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 606 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Em relação à Kelly Cristina Castilho Fonseca

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta da ré, deve ser considerada normal. A acusada não possui antecedentes. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas foram apreendidas em quantidade elevada, a natureza da droga apreendida, de alto poder destrutivo enseja o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, permanece a reprimenda em 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na derradeira fase da dosimetria, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois as circunstâncias da abordagem indicam a dedicação a atividades criminosas. Presente a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006 pois o intuito da ré era transportar os entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nesse sentido, aumento a reprimenda na fração de 1/6, e fixo-a, definitivamente em 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 729 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para:

(i) ABSOLVER Jonathan Soares da Silva da imputação alusiva ao art. 35, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e CONDENAR Jonathan Soares da Silva como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 606 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas;

(ii) ABSOLVER Kelly Cristina Castilho Fonseca da imputação alusiva ao art. 35, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e CONDENAR Kelly Cristina Castilho Fonseca como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 729 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Os réus deverão cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado ante a gravidade concreta do delito, indicando a necessidade da imposição do regime mais rigoroso. (cf. artigo 59, III, c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Em razão da quantidade da pena, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I do Código Penal) bem como a concessão de sursis (artigo 77, caput, do Código Penal). Além da gravidade concreta da conduta demonstrar que não seria socialmente recomendável.

Deve permanecer suas custódias cautelares, pois não modificadas as situações que demandaram suas necessidades (CPP, art. 387, § 1.º). Trata-se de crime de exacerbada gravidade (tráfico interestadual de entorpecentes), que fomenta a criminalidade e discórdia familiar nas grandes e pequenas cidades e coloca em constante desassossego a sociedade e a segurança dos cidadãos de bem. Dessa forma, a decretação da custódia cautelar permanece necessária como medida que se impõe para assegurar a ordem pública.

Ademais, no aspecto, como bem asseverado pelo Ministro Jorge Mussi, no julgamento do Habeas Corpus 68.455/DF não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

2. No caso, constatado que o paciente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto construtivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-

lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo.

3. Constatado que o pedido de alteração do regime prisional não foi analisado pelo Tribunal a quo no julgamento do writ originário, fica esta Corte impedida de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Ademais, o tema deve ser apreciado no recurso de apelação já interposto.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 279.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

Rememore-se o teor do enunciado da súmula 716 do STF: "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Carreio aos acusados o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Maracai, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA